

<제07장 취소소송의 가구제.제02절 가처분>

[예상][7.02-1]항고소송에서 민사소송법상 가처분 규정의 준용 여부에 관한 학설 및 판례의 입장

《【문제7.2】

<사례>

행정청 A는 甲에게 개발행위허가 취소처분을 내렸다. 甲은 해당 취소처분에 대해 취소소송을 제기하면서, 소송이 진행되는 동안 해당 부지에 대한 공사를 계속 진행하기 위해 집행정지를 신청하였으나 법원에 의해 기각되었다. 이에 甲은 행정소송법 제8조 제2항에 따라 민사소송법상의 가처분 규정을 준용하여 법원에 공사 중지를 막아달라는 취지의 임시처분을 신청하고자 한다. 한편, 乙은 행정청 B에게 수익적 처분을 신청하였으나 거부처분 취소소송을 제기하면서 판결 확정 전까지 임시로 해당 수익적 지위를 설정해 달라는 가처분을 신청하였다.

(물음1) 항고소송에서 민사소송법상 가처분 규정이 준용될 수 있는지에 대하여 학설의 대립과 대법원 판례의 입장을 기술하라.》

<문제7.2의 물음1> 항고소송에서 민사소송법상 가처분 규정의 준용 여부에 관한 학설 및 판례의 입장

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 개발행위허가 취소처분에 대한 취소소송 중 집행정지 신청이 기각되자 가처분을 통한 권리보호를 시도하고, 乙은 거부처분 취소소송 중 수익적 지위를 임시로 확보하기 위한 가처분을 신청하려는 상황이다. 쟁점으로 <항고소송에서 행정소송법상 집행정지 제도 외에 민사소송법상 가처분 규정의 준용이 가능한지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 항고소송에서 가처분 준용 가능성에 관한 학설과 판례의 입장을 기술한다.

II. 가처분의 의의 및 행정소송 가구제와의 관계

1. 가처분의 개념

- 가처분이란 금전채권 이외의 권리 또는 법률관계에 관한 확정판결의 강제집행을 보전하기 위하여 임시로 내려지는 명령을 말한다. 민사소송법상 가처분은 현상의 변경을 금지하는 다툼의 대상에 관한 가처분과 임시의 지위를 설정하는 임시처분으로 구분된다.

2. 집행정지와와의 차이

- 행정소송법 제23조가 규정하는 집행정지는 기존 처분의 효력이나 집행을 잠정적으로 정지시키는 소극적 가구제 수단이다. 반면 민사소송법상의 임시처분적 가처분은 신청인에게 임시의 지위를 부여하거나 적극적인 행위를 명하는 적극적 가구제 수단의 성격을 갖는다.

III. 가처분 규정 준용 여부에 관한 학설 및 판례

1. 학설의 대립

(1) 긍정설

- 행정소송법 제8조 제2항에 의해 민사소송법 규정이 준용될 수 있고, 집행정지만으로는 거부처분이나 부작위와 같은 사안에서 실효적인 권리구제가 불가능하므로 가처분이 인정되어야 한다는 견해이다. 헌법상 재판받을 권리와 실질적 법치주의의 구현을 근거로 한다.

(2) 부정설

- 행정소송법 제23조가 집행정지 제도를 별도로 두고 있는 것은 항고소송에서 가처분을 배제하려는 입법 취지로 해석한다. 또한, 가처분을 인정할 경우 행정권의 1차적 판단권을 침해하고 권력분립 원칙에 반할 우려가 있다는 점을 근거로 한다.

(3) 절충설

- 원칙적으로 부정하되, 집행정지만으로는 도저히 구제할 수 없는 예외적인 경우에 한하여 보충적으로 가처분을 허용하자는 견해이다.

2. 대법원 판례의 입장

(1) 항고소송에서의 부정

- 대법원은 항고소송인 취소소송이나 무효확인소송에서 민사소송법상의 가처분 규정이 준용될 수 없다는 입장을 일관되게 유지하고 있다. 판례는 행정처분의 집행정지 사건에서 행정소송법 제23조의 집행정지 규정은 민사소송법상의 가처분에 대한 특칙이므로, 항고소송에서는 집행정지만이 허용될 뿐 가처분은 허용되지 않는다고 판시한다.

(2) 거부처분에 대한 판단

- 특히 거부처분에 대한 취소소송에서도 대법원은 가처분을 부정한다. 거부처분 취소소송에서 가처분을 통해 임시 지위를 설정하는 것은 행정청에 특정 행위를 강제하는 결과를 초래하여 사법권의 한계를 넘어서는 것으로 본다.

(3) 당사자소송과의 비교

- 다만 대법원은 국가를 상대로 한 당사자소송에서는 행정소송법 제44조 제1항이 집행정지 규정을 준용하지 않고 있으므로, 민사소송법상의 가처분 규정이 준용될 수 있다고 보아 항고소송과 결론을 달리하고 있다.

IV. 사안의 적용

1. 甲의 임시처분 신청에 대한 검토

- 甲이 신청하고자 하는 가처분은 취소소송 과정에서 공사 중지를 막아달라는 취지의 지위 설정이다. 대법원 판례의 법리에 따르면, 취소소송에서는 행정소송법 제23조의 집행정지 규정이 우선 적용되며 민사소송법상의 가처분은 준용되지 않는다. 따라서 甲의 가처분 신청은 법원에 의해 부적법한 것으로 판단될 가능성이 높다.

2. 乙의 가처분 신청에 대한 검토

- 乙은 거부처분 취소소송에서 수익적 지위 설정을 구하는 가처분을 신청하였다. 거부처분의 경우 집행정지를 하더라도 처분 전의 상태인 신청 시로 돌아갈 뿐이어서 실효성이 없다는 비판이 있으나, 판례는 여전히 권력분립과 특칙 우선의 원칙을 이유로 항고소송에서의 가처분을 부정하므로 乙의 신청 역시 받아들여지기 어렵다.

V. 결론

- 현행법 체계와 대법원 판례의 확립된 태도에 의하면 항고소송에서는 민사소송법상의 가처분 규정이 준용될 수 없다. 이는 행정소송법 제23조가 집행정지를 특칙으로 규정하고 있기 때문이며, 사법권이 행정권의 영역에 적극적으로 개입하여 임시 지위를 설정하는 것을 경계하는 취지이다. 따라서 사안의 甲과 乙의 가처분 신청은 모두 허용되지 않는다는 것이 판례의 관점이다. 이러한 법리는 행정소송에서의 가구제 수단이 소극적인 집행정지에 국한되어 있다는 한계를 보여주며, 향후 입법적 개선을 통해 임시처분 제도의 도입 필요성이 논의되는 배경이 된다.